



DELIBERA N. 27

30 gennaio 2025.

Oggetto

Istanza CONGIUNTA per ADESIONE presentata dal Comune di Agira e [OMISSIS]- Lavori di ristrutturazione dell'Asilo nido presso l'edificio Comunale dell'ex Convento S. Agostino ad Agira_ Affidamento mediante procedura negoziata senza Bando, ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. c) del d.lgs. n. 36/2023. CIG: G82B24008370007 Importo a base di gara: euro 296.295,26 S.A.: Comune di Agira.

UPREC-PRE-0398-2024-L-PREC

Riferimenti normativi

Articolo 100 del d.lgs. 36/2023

Articolo 101 d.lgs. 36/2023

Parole chiave

appalto pubblico – lavori – scelta del contraente – criteri – gara – soccorso istruttorio – modificazione offerta

Massima

NON MASSIMABILE

Il Consiglio dell'Autorità Nazionale Anticorruzione

nell'adunanza del 30 gennaio 2025



DELIBERA

VISTA l'istanza proposta dal Comune di Agira, acquisita al prot. gen. ANAC n. 740 del 3.1.2025, e la successiva adesione formulata in data 6.1.2025 – prot. 1074 dall'o.e. [OMISSIS] d con la quale hanno chiesto alla scrivente Autorità di voler esprimere un parere di precontenzioso relativamente alla legittimità della aggiudicazione disposta a favore della ditta aderente sulla base di chiarimenti resi a seguito di soccorso istruttorio con riferimento all'importo dell'offerta economica;

VISTO l'avvio dell'istruttoria comunicato con nota prot. n. 2160 del 8.1.2025;

VISTA la documentazione in atti e le memorie presentate dalle parti;

CONSIDERATO che la questione controversa sottoposta all'Autorità verte essenzialmente sulla legittimità dell'aggiudicazione che nel dettaglio è stata disposta a seguito della esclusione delle offerte anomale, tra cui quella di altro concorrente la cui offerta è stata ammessa solo a seguito dei chiarimenti sulla stessa a seguito di soccorso istruttorio, perché il ribasso era stato offerto come valore percentuale invece che come valore assoluto;

PRESO ATTO preliminarmente che ai sensi della lex specialis di gara, segnatamente l'art. 10 della lettera di invito – disciplinare prevede che *"L'appalto verrà aggiudicato utilizzando il criterio del minor prezzo così come previsto dall'art. 50 comma 4 del D.lgs. n. 36/2023; ed in particolare mediante: massimo ribasso percentuale del prezzo offerto rispetto all'importo complessivo dei lavori a base di gara al netto degli oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza"*. La stazione appaltante, tuttavia, riferisce che al momento della predisposizione della procedura sul sito MEPA *"nell'inserimento della gara sulla piattaforma è stata flaggata l'opzione dell'offerta in cifre anziché in percentuale"*, con l'effetto di un evidente contrasto nelle modalità di indicazione dell'offerta;

RILEVATO che, come risulta dal verbale di gara, sono state esaminate le offerte riferite ai 5 partecipanti di cui tuttavia 4 sono state formulate come valore assoluto senza indicazione, pertanto, del ribasso percentuale (con valori compresi tra 226.014,02 a 280.212,88 €), mentre una (o.e. IMPRESALV s.r.l.) indicava un valore pari a 26,12. In esito a ciò la Commissione richiedeva chiarimenti tramite la piattaforma MEPA all'o.e. suddetto, attivando soccorso istruttorio ex art. 101 del d.lgs 36/2023. L'o.e. formulava in tempo reale il chiarimento con cui dichiarava *"che il ribasso percentuale è di 26,12% equivalente a euro 77.392,32 pertanto l'importo offerto per i lavori sarà di euro 218.902,94 depurato dal ribasso d'asta del 26,12% oltre gli oneri per la sicurezza pari ad euro 40.213,72"*;

PRESO ATTO di quanto sopra, la Commissione di gara, ritenute valide tutte e 5 le offerte, procedeva al calcolo e alla valutazione dell'anomalia escludendo le due offerte superiori alla soglia ([OMISSIS])e aggiudicando provvisoriamente all'o.e. [OMISSIS];

CONSIDERATO che erano nel frattempo pervenute alla stazione appaltante le contestazioni dell'o.e. [OMISSIS], con cui veniva censurata tale aggiudicazione sul presupposto della insanabilità delle irregolarità dell'offerta economica mediante il ricorso al soccorso istruttorio, il Comune di Agira formulava l'odierna istanza di precontenzioso chiedendo conferma della correttezza della propria condotta in sede di attivazione del soccorso istruttorio e della legittimità dell'ammissione dell'offerta dell'o.e. [OMISSIS] risultata decisiva ai fini dell'aggiudicazione all'o.e. Laneri, che ha aderito all'istanza de qua;



CONSIDERATO in via preliminare che ai sensi dell'art. 101 co. 3 del d.lgs 36/23 *"La stazione appaltante può sempre richiedere chiarimenti sui contenuti dell'offerta tecnica e dell'offerta economica e su ogni loro allegato. L'operatore economico è tenuto a fornire risposta nel termine fissato dalla stazione appaltante, che non può essere inferiore a cinque giorni e superiore a dieci giorni. I chiarimenti resi dall'operatore economico non possono modificare il contenuto dell'offerta tecnica e dell'offerta economica"*. Secondo le indicazioni giurisprudenziali di riferimento si tratta del *"soccorso istruttorio in senso stretto (comma 3), che - recuperando gli spazi già progressivamente riconosciuti dalla giurisprudenza alle forme di soccorso c.d. procedimentale - abilita la stazione appaltante (o l'ente concedente) a sollecitare chiarimenti o spiegazioni sui contenuti dell'offerta tecnica e/o dell'offerta economica, finalizzati a consentirne l'esatta acquisizione e a ricercare l'effettiva volontà dell'impresa partecipante, superandone le eventuali ambiguità, a condizione di pervenire ad esiti certi circa la portata dell'impegno negoziale assunto, e fermo in ogni caso il divieto (strettamente correlato allo stringente vincolo della par condicio) di apportarvi qualunque modifica"* (cfr. ex multis Consiglio di Stato, Sez. V, sentenza del 31 luglio 2024 n. 6875). Per tale ragione si può parimenti ritenere che *"nelle gare pubbliche è ammissibile un'attività interpretativa della volontà dell'impresa partecipante alla gara da parte della stazione appaltante, al fine di superare eventuali ambiguità nella formulazione dell'offerta, purché si giunga ad esiti certi circa la portata dell'impegno negoziale con essi assunti; evidenziandosi, altresì, che le offerte, intese come atto negoziale, sono suscettibili di essere interpretate in modo tale da ricercare l'effettiva volontà del dichiarante, senza peraltro attingere a fonti di conoscenza estranee all'offerta medesima né a dichiarazioni integrative o rettificative dell'offerente"* (cfr. TAR Lazio – Roma sez. II, sentenza 11 dicembre 2023 n. 18735);

RITENUTO il quadro normativo e giurisprudenziale sopra riportato si osserva in primo luogo che nel caso di specie, non pare sussistano dubbi circa la non intelligibilità dell'offerta nella sua formulazione manifesta anche in confronto alle altre offerte pervenute. Parallelamente a ciò, tenuto conto, da un lato, dell'evidente contrasto tra le previsioni della lex specialis rispetto alle modalità operative attivate nella piattaforma MEPA per l'indicazione dell'offerta, da un altro, che il valore offerto sarebbe del tutto privo di senso se considerato in senso assoluto (un'offerta di € 26,12 a fronte di una base d'asta di 296.295,23), senza trascurare da ultimo che, sempre alla luce della normativa di riferimento e della disciplina di gara, un'offerta anche minima – a rigore – non avrebbe determinato l'esclusione dell'o.e. (ma al limite avrebbe determinato la predisposizione di una diversa graduatoria), pare del tutto corretto l'operato della stazione appaltante che ha opportunamente richiesto dei chiarimenti sul contenuto dell'offerta stessa, attivando la precipua fattispecie dell'art.101, co 3 del d.lgs 36/2023

CONSIDERATO che, con riferimento al secondo quesito inerente le valutazioni assunte dalla stazione appaltante, si osserva che il contenuto del chiarimento reso, sebbene quasi al limite ermeneutico consentito, tuttavia appare coerente - nella ricostruzione del suo significato in modo certo facendo applicazione dei noti criteri interpretativi di cui agli artt. 1362-1371 c.c., con particolare riferimento al principio della buona fede, sancito anche dall'art. 5 del decreto legislativo n. 36/2023 – con il contenuto della stessa lex specialis che richiedeva l'offerta espressa non in valore assoluto, ma invero solo come ribasso percentuale. Peraltro, giova evidenziare che anche l'immediatezza del chiarimento reso dall'o.e. attraverso la piattaforma MEPA depone nel senso che quanto offerto dalla[OMISSIS] fin dall'inizio fosse da intendere come un valore percentuale;

CONSIDERATO quanto sopra deve pertanto osservarsi che, alla luce del "principio di immodificabilità dell'offerta che non consente di accettare come giustificativo del prezzo offerto il chiarimento che determini una variazione postuma dei contenuti dell'offerta economica, non sorretta da elementi chiari



e univoci desumibili dall'offerta stessa" (cfr. ex multis ANAC delibera n. 183 del 3.5.2023), la condotta della stazione appaltante risulta conforme alla normativa di riferimento. In tal senso, pur avendo tardivamente preso atto del contrasto tra la *lex specialis* e le modalità operative previste nella piattaforma MEPA che avrebbe necessitato di un tempestivo intervento chiarificatore, il Comune di Agira ha utilizzato correttamente l'istituto del soccorso istruttorio di cui all'art. 101, comma 3, richiedendo chiarimenti sull'offerta dell'o.e.[OMISSIS], senza che venisse operata alcuna modificazione del contenuto della stessa, ragionevolmente al solo fine di una sua confrontabilità con le offerte degli altri operatori economici le cui offerte erano state presentate in conformità alle diverse prescrizioni della piattaforma MEPA e come tali – in coerenza con i principi della fiducia (art. 2) e del risultato (art. 1), rispetto alla quale il principio di concorrenza e di massima partecipazione alla gara è funzionale (art. 1, comma 2) – ritenute ammissibili;

Il Consiglio

ritiene, sulla base di tutte le motivazioni che precedono, che:

- la attivazione del soccorso istruttorio c.d. in senso stretto appare correttamente posta in essere stante la presenza dei giusti presupposti;
- l'acquisizione dei chiarimenti anzidetti ha consentito di individuare legittimamente l'effettivo valore offerto, ai fini di una sua confrontabilità con le offerte degli altri concorrenti;
- invita infine la stazione appaltante a prestare maggiore attenzione allo sviluppo delle fasi operative delle procedure di gara in particolare che queste avvengano coerentemente alle regole autoimposte con la *lex specialis*.

Il Presidente
Avv. Giuseppe Busia

Depositato presso la segreteria del Consiglio in data 3 febbraio 2025
Il Segretario Valentina Angelucci

Firmato digitalmente